

0018316-23.2015.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS DE MANEIRA AUTÔNOMA E EM CONCURSO COM DISTINTOS COMPARSAS. CONDIÇÕES DE LUGAR E DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018316-23.2015.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018316-23.2015.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 1506/2015 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO ROBERTO BERALDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Fernando Roberto Beraldo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 168 do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 20 de janeiro de 2015, na rua Antônio Alves, nº 29-16, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, apropriou-se de, aproximadamente, 472.030 reais, de 'J. Bueno Sociedade de Advogados', representado por José Edgard da Cunha Bueno Filho, em razão de seu emprego.

Documentos (fls. 02/45), laudo pericial (fls. 113/118), relatório policial final (fls. 178/182), planilha (fls. 372/378), documentos (fls. 534/605), guias pagas (fls. 864/871).

Pela decisão de fls. 193/194, foi recebida a denúncia e determinada a citação do

acusado.

A vítima foi admitida como assistente de acusação (fls. 243).

O réu foi citado (fls. 256), sendo ofertada resposta à acusação (fls. 260/272).

Na decisão de fls. 278, foi mantido o recebimento da exordial.

A testemunha Roberto Minori Ischy foi ouvida mediante carta precatória (fls. 332).

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls.

379/381, o réu não concordou com o ANPP. No mesmo ato processual, as partes

desistiram da oitiva da oitiva de José Edgar da Cunha Bueno Filho, pleito homologado. Na mesma ocasião, requereram a oitiva do ofendido Reinaldo Luis Tadeu

Rondina. Na mesma toada, foram ouvidos Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti,

Fabiana Augusto Zacaib Pierim, Karina de Almeida Batistuci, Sandra Luzia Gibim

Beraldo e Marco Antônio Loureiro Soares.

Na audiência em continuação de fls. 844/846, foi indeferido o pedido de oitiva, em data posterior de Faissal Rafik Saab e foi interrogado o réu.

A decisão de fls. 931/934 declarou encerrada a instrução criminal.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 942/954 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, pelo delito de estelionato, em emendatio

libelli. Pediu, ainda, pelo o afastamento do crime continuado, em razão da

extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias, bem como pela habitualidade/reiteração delitiva, sugerindo o lançamento da pena em 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A D. Assistência da Acusação, ofertou alegações finais às fls. 955/960 referendando ao citado pelo Parquet, com acréscimo da necessidade da reparação mínima, nos termos do art. 387, IV do CPP.

Já a C. Defesa às fls. 969/982 pleiteou, em preliminar, a ilegitimidade da Assistência da Acusação, já que o correto seria a presença do Banco Itaú, e, no mérito, pela absolvição, por ausência de provas, já que terceiros também teriam acesso ao sistema, e a atividade do acusado era fiscalizada pelos coordenadores.

Afirmou, ainda, que o acusado foi coagido e ameaçado para assinar 'a escritura de confissão', além de ter tido os dados quebrados perante a Receita Federal, sem qualquer autorização. Disse, por fim, que o patrimônio pertencente pelo acusado é proporcional à sua renda, fatores que levaram à almejada absolvição, nos termos do art. 386, VI ou VII do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de ilegitimidade merece ser ultrapassada.

Com efeito, ainda que o acusado tenha feito parte dos quadros do Banco Itaú, havia contrato vigente de prestação de serviços entre a instituição financeira.

Tanto é assim que o escritório de advocacia arcou com os prejuízos (fls. 851/853).

Além disso, o contrato de emprego "inicial" foi firmado com o escritório de advocacia (fls. 09/12).

Em seguida, após o acusado ter sido contratado como "advogado", o contrato de trabalho foi intermediado, até a rescisão, por 'Finch Brasil Soluções Integradas de Tecnologia LTDA', uma holding, todavia, por certo, ainda no âmbito do escritório. Por isso, a legitimidade da assistência é patente.

Deste modo, fica rejeitada a preliminar.

Passemos ao mérito.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente, ante o conjunto probatório amealhado aos autos.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos documentos (fls. 02/45), laudo pericial (fls. 113/118), relatório policial final (fls. 178/182), planilha (fls. 372/378), documentos (fls. 534/605), guias pagas (fls. 864/871).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O ofendido Reinaldo Tadeu Mandaliti, sócio majoritário da empresa-vítima, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que os executivos da empresa reportaram o ocorrido. Afirmou que foi determinada a realização de uma auditoria. Informou que, em uma reunião, o acusado confessou os fatos reportados na denúncia.

Esclareceu que o sistema exige do operador uma senha para cada funcionário ter acesso. Mencionou que o acusado também era o encarregado do setor. Citou que ele 'aprendeu como fazer o golpe com outro funcionário': Marçal. Asseverou que ele restituiu os valores, bem como entregou um veículo (cerca de 50 mil) como parte da indenização. Disse que os prejuízos chegaram perto de 500 mil reais. Afirmou que o acusado era o responsável pela edição das guias. Informou que o procedimento consistia em 'alterar o código de barras das guias'. Esclareceu que, como não foram feitos, efetivamente, os recolhimentos, por meio das guias, teve que ressarcir o prejuízo causado. Mencionou que, na frente dos cartórios, quando da lavratura da 'escritura de confissão', o acusado se mostrou tranquilo em reportar os fatos, mostrando-se arrependido. Citou que ele se comprometeu a restituir valores, mas não o fizera. Asseverou que a contabilidade da empresa constatou os golpes. Disse que o acusado, para efetivação do desvio, fazia compras pela internet, como nas Lojas Americanas, depois cancelava a compra, ficando com o dinheiro.

A testemunha Fabiana Augusto Zacaib Pierim, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disse, em resumo, que, certa vez, o setor financeiro lhe avisou que havia duas guias idênticas, no valor de 2 mil reais. Afirmou que, ao verificar os autos do processo, não havia razão para pagamento de valores. Informou que foi possível verificar que, com o recurso "recorta e cola," os códigos de barra assim como outras informações contidas na guia não correspondiam àquele processo. Em face disto, soube que realizaram uma auditoria. Esclareceu que o acusado, por anos, era encarregado de emitir as guias para recolhimentos. Mencionou que o acusado confessou os golpes, tendo se comprometido a restituir os valores, dando um veículo como forma de ressarcimento. Citou que os prejuízos atingiram o montante, aproximado, de 400 mil reais. Asseverou que o acusado alterava as guias e fazia compras pela internet. Disse que o réu foi visto oferecendo equipamentos eletroeletrônicos para os funcionários. Afirmou que ele fazia também o cancelamento das compras para que o dinheiro fosse creditado da conta bancária dele. Informou que a auditoria se valeu do computador que era utilizado pelo acusado. Esclareceu que 'foram meses de trabalhos para relacionar as guias com os processos e esclarecer como o réu agiu para lesar a empresa'. Mencionou que ele chegou a usar o nome de outra funcionária, Valdinei, a fim de evitar o esclarecimento da autoria. Citou que tinha muita confiança no réu, quanto à sua lisura e jamais imaginava que ele teria coragem de assim agir. Asseverou que o acusado gerava a guia e solicitava o pagamento por parte do financeiro. Disse que não era de responsabilidade do financeiro certificar-se quanto a autenticidade das guias.

A testemunha Karina de Almeida Batistuci, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que, em meados de maio de 2014, foram notadas, pelo financeiro, duas guias para pagamento. Afirmou que verificou que a numeração correspondia a um processo para pagamento das custas, em face da apelação. Informou que, examinando os autos, nem sequer havia sido proferida a sentença. Esclareceu que foi feita uma auditoria interna, na base de trabalho, numa carteira, onde constatarem um grande número de guias, a maioria era pagamento de compras feitas pela internet, em especial compras de celulares. Mencionou que, em uma reunião, o acusado foi chamado, quando ele confessou as fraudes. Citou que os fatos chegaram ao conhecimento da administração superior da empresa e providências foram adotadas. Asseverou que estava presente no cartório, quando ele confessou, assinando a escritura pública, que foi lavrada num cartório de notas. Disse que, muitos valores "caíam" nas contas bancárias dele, em especial no banco Itaú. Afirmou que acompanhou o acusado ao banco onde ele fez saques, devolvendo o valor de 52 mil reais. Informou que, para concretizar os golpes, o acusado fazia o cancelamento das compras e as lojas devolviam o dinheiro, na conta bancária dele. Esclareceu que alguns clientes foram prejudicados, mas foram ressarcidos pela empresa. Mencionou que não foi apurado o número de compras que o acusado realizou pela internet.

A testemunha Roberto Minori Ishy, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que foi contratado pelo grupo JBM para averiguar possíveis fraudes que estariam ocorrendo no setor de pagamento. Afirmou que desconfiou do réu e decidiu por fazer uma perícia no computador dele. Informou que, durante as investigações, o acusado confessou a prática da fraude. Esclareceu que ele modificava os códigos de

barra e desviava o valor para uma conta de uma empresa americana. Mencionou que os bens que ele possuía eram incompatíveis com a renda. Citou que ele foi até o cartório e fez uma confissão pública da fraude.

A testemunha Sandra Luzia Gibin Beraldo, esposa do acusado, em juízo (mídia SAJ), em resumo, disse que o réu foi ameaçado e coagido a pedir demissão porque havia alguns valores desviados da empresa. Afirmou que ele contou que nada fez de ilícito. O réu acabou devolvendo um veículo e alguns valores. Informou que possuíam um GM/Spin, mas, depois, ele trocou por uma caminhonete Frontier, não sabendo precisar a “diferença” entre eles. Esclareceu que o réu não comprava mercadorias pela internet, nem vendia celulares.

A testemunha Marco Antônio Loureiro Soares, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), prestou apenas relatos referenciais no tocante ao acusado.

O acusado Fernando Roberto Beraldo, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática dos crimes. Disse que foi chamado no escritório 'J Bueno' e acusado de ter roubado mais de meio milhão da empresa. Afirmou que disseram que havia alterado guias de pagamento, mas nunca teve tal obrigação. Informou que tinha a função de preencher formulários, que recebia do banco Itaú, trabalhando, no local, por três anos. Esclareceu que trabalhava com outras 40 pessoas e que tudo que fazia era revisto por advogados e por seus superiores. Mencionou que foi levado até uma sala e obrigado a assinar um documento. Citou que seu único bem é uma residência que foi adquirida antes de entrar na empresa. Asseverou que ganhava cerca de “mil e pouco” reais. Disse que soube que alguns advogados faziam compras nas lojas Americanas. Afirmou, ainda, que outras pessoas usavam seu computador, podendo facilmente usar seu e-mail oficial.

Pela prova colhida, em que pese a negativa do acusado, tem-se que a prova é contundente.

Com efeito, a própria esposa do réu mencionou que ele devolveu valores e uma caminhonete ao escritório.

Assim, não é crível que tenha sido ameaçado ou coagido a assinar, inclusive, a escritura de confissão de dívida de fls. 44, na qual consta a menção expressa da devolução de montante e do veículo Nissan.

Tampouco é possível constatar que foi realizada a quebra do sigilo do acusado, fora das hipóteses legais.

De início, a parte contratou auditoria interna e, através dela, segundo consta, chefiada pelo Sr. Roberto Minory Ishiy restou consignado que as informações da Receita Federal são públicas (fls. 171/172).

Além disso, elas encontram eco no restante da prova colhida, mediante a qual restou comprovado que o acusado falsificava guias de recolhimento, sem lastro, e inseria números de código de barras para compras na internet, ora para efetivamente adquirir os produtos (os quais oferecia para venda), e, também para cancelar a compra e efetivamente “recuperar” o dinheiro que nunca foi seu.

Aqui, um parêntese.

O montante de desvio nunca foi entregue pela empresa-vítima.

Em relação de confiança, até pelos anos de serviços desempenhados, o acusado gerava as guias e as fraudava.

Elas eram pagas e somente após o acusado angariava ora produtos (especialmente celulares) ou dinheiro, após o cancelamento das compras (fls. 534/605).

Por isso, respeitado o entendimento em contrário, não é caso de estelionato, mas sim, de permanência como desapropriação, por isso, sem necessidade da emendatio libelli.

Com o fechamento do parêntese, resta citar que a fraude foi descoberta após muito tempo, somente com a emissão de duas guias em um mesmo processo, que jamais foram pagas, segundo delineou a prova produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Depois disso, em procedimento, foram apuradas as fraudes, as quais, inclusive, o acusado tentava ocultar, com a utilização de senhas de outras pessoas, sem o sucesso almejado.

De outro lado, o patrimônio do acusado não é compatível com seus ganhos.

Ora, o próprio afirmou que ganhava cerca de mil reais, o que pode ser confirmado

pelo termo de rescisão, no qual o saldo líquido foi de pouco mais de 1.300 reais (fls. 21).

Além disso, em interrogatório, o réu afirmou que só tinha uma residência adquirida antes de ser admitido no escritório.

Por tudo, há provas contundentes para o édito condenatório.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no piso, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, presente a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III do Código Penal.

Como dito, o acusado emitia as guias com códigos de barra fraudados em razão de seu emprego, diga-se, relação de confiança perpetrada pelos anos de serviços prestados.

Deste modo, a reprimenda deve ser acrescida em 1/3, atingindo 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sob outro vértice, diversamente do alegado pelo Parquet, com toda vênia de sempre, tem-se que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, não caracterizada a habitualidade.

Eis a redação do art. 71 "caput" do Código Penal: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Os crimes da mesma espécie foram cometidos entre 2011 e 2014.

As infrações foram perpetrados dentro do mesmo âmbito espacial e semelhante modus operandi.

Por isso, os crimes, desde que respeitado o lapso jurisprudencial de 30 (trinta) dias, caracterizam a citada ficção jurídica.

Nesse sentido, por vias transversas:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS DE MANEIRA AUTÔNOMA E EM CONCURSO COM DISTINTOS COMPARSAS. CONDIÇÕES DE LUGAR E DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS DELITOS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE SUPERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

- O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

- In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS -, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes.

- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.

Precedentes.

- Realizada a análise do cálculo dosimétrico para todos os delitos, verifico que ele obedeceu integralmente ao tecnicismo e aos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte Superior, inexistindo ilegalidade a ser sanada nas sanções aplicadas.

- Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 726185 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/03/2022)

Os grupos de continuidade delitiva são os seguintes (fls. 05/06 e 372/378): 1) junho a outubro/2011; 2) janeiro a março/2012; - 3) maio a dezembro/2012; - 4) janeiro a dezembro/2013; - 5) janeiro a maio/2014.

O parâmetro de pena a sofrer a modificação é atingindo 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Depois, ainda que alguns grupos gozem de menos extensão temporal, fato é que, de acordo com a prova colhida, várias foram as falsificações.

Por isso, cada um dos grupos deve observar a soma de 2/3, perfazendo 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e uma) diárias.

Sendo cinco os grupos, e somadas as penas em razão da ultrapassagem do lapso de 30 (trinta) dias - concurso material -, tem-se, em definitivo, 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias atuais no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º "a" do Código Penal, eis que o único apto a atender às finalidades da reprimenda, quais sejam, preventiva e repressiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na ação penal e, em consequência, CONDENO o réu FERNANDO ROBERTO BERALDO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 168, §1º, III c.c. 71 "caput" todos do Código Penal.

Nos termos do art. 387, IV do CPP, fixa-se o valor de R\$ 332.030,78 (fls. 06), como o montante mínimo à título de reparação pelos prejuízos sofridos.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição deve continuar, por ausentes os pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA